

1500241-12.2021.8.26.0535

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... de direito - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500241-12.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500241-12.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CARDOSO DOS SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

DIEGO CARDOSO DOS SANTOS E DIEGO FERNANDO DOS SANTOS DOBKOWSKI, qualificados no autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no 22 de janeiro de 2021, por volta das 12:45 horas, à Rua Três, 150, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade, traziam consigo e guardavam drogas, consistentes em 49,08 gramas (peso líquido) de maconha, acondicionadas em 45 porções; 1,7 gramas (peso líquido) de cocaína, acondicionado em 38 eppendorfs e 16,27 gramas (peso líquido) de crack, acondicionado em 30 eppendorfs, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, droga essa que causa dependência física e psíquica.

Narra a acusação que os acusados estavam previamente ajustados e imbuídos em praticarem tráfico de drogas e se dirigiram ao local acima indicado, portando as drogas fracionadas para comercialização. Na mesma data policiais militares receberam delação dando conta de ocorrência de tráfico de drogas numa viela que interliga a rua Três e a antiga Rua Quatro. Os policiais se deslocaram para o local e um policial desembarcou da viatura, seguindo a pé pela rua Quatro, enquanto outro, o policial Jonatas, seguiu pela rua Três. Ao se aproximar da viela o policial Jonatas viu os acusados juntos e um deles, Diego Cardoso, vestia camiseta

preta e trazia consigo uma sacola plástica. O acusado Diego Fernando trajava camiseta branca e ao notar a presença da viatura começou a gritar "moio, moio". O acusado Diego Cardoso, então, correu pela viela em direção da rua Quatro, onde estava o policial Willian. O acusado Diego Fernando permaneceu parado e foi abordado pelo policial Jonatas, nada de ilícito sendo encontrado com ele. O policial Jonatas comunicou via telefone ao seu colega Willian que Diego Cardoso seguia em direção dele, vestindo camiseta preta e com sacola nas mãos. Após, ao ser indagado, Diego Fernando disse que trabalhava como "olheiro" e sua função era gritar caso percebesse a presença de viatura. Durante a fuga de Diego Cardoso, este dispensou a camiseta preta para despistar o policial e em seguida, dispensou a sacola, fato que foi presenciado pelo policial Willian, que o abordou.

Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01. Boletim de Ocorrência às fls.05/08. Auto de exibição e apreensão às fls.09/10. Laudo de constatação (fls. 12/17).

A decisão de fls. 75/79 converteu o flagrante em prisão preventiva aos acusados.

Laudo pericial toxicológico definitivo às fls. 113/115.

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 151/152 e 160/162.

A denúncia foi recebida em 23/08/2021, às fls. 176/177.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls. 241/245).

O Ministério Público em alegações finais orais, pugnou pela procedência da denúncia. Quanto à dosimetria, altercou que em primeira fase deve ser em patamar mínimo. Na segunda fase, o acusado Diego Fernando confessou o delito, mas é reincidente. Sustentou que não cabe o reconhecimento de tráfico privilegiado, ante a reincidência do acusado Diego Fernando, e por existir quantidade e natureza diversas de drogas, que eram traficadas em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Em alegações finais (fls. 246/258), a defesa do acusado Diego Fernando requereu a absolvição do acusado, com o reconhecimento de atipicidade da conduta, afirmando que o acusado não trazia drogas consigo e somente teria a função de olheiro de terceiro que traficava. Sustentou existir exclusão de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o acusado seria usuário de drogas e estaria em situação de rua, por dependência química. Sustentou que não havendo elementar do tipo penal de tráfico, deve ocorrer a desclassificação para o delito do art. 37, da lei de Drogas. Ainda, argumentou sobre a possibilidade, subsidiária, de reconhecimento de tráfico privilegiado. Quanto à dosimetria da pena, sustentou que o acusado é dependente de drogas, motivo a ser considerado em primeira fase. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da confissão. Requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a imposição de pena restritiva de direitos. Pugnou pela detração.

O acusado Diego Cardoso apresentou alegações finais de fls. 259/262, pugnando pela absolvição do acusado, ante ausência de provas para a condenação. Requereu, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, laudo de constatação da substância

entorpecente, laudos periciais e prova oral produzida.

A sua autoria dos réus segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha Jonatas Carlos Barbosa, policial militar, disse que na data dos fatos o Copom passou ocorrência de tráfico de entorpecentes na rua apontada na denúncia, local conhecido como ponto de venda de drogas. Pararam a viatura e desceu pela rua 3 e o parceiro pela rua 4. Viu dois indivíduos na viela e um deles gritou "moio". O outro saiu correndo e deu de frente com seu parceiro. Seu parceiro abordou o outro indivíduo que trazia entorpecentes. Declarou que o Diego Cardoso era quem portava a droga. Recorda-se vagamente dos acusados. A droga era crack, cocaína e maconha. Não conhecia os réus anteriormente. O acusado que abordou alegou, na abordagem, que era olheiro e iria ganhar crack por ficar no local. Disse que a droga foi achada por seu parceiro e não se recorda a quantidade. Na viela estavam só os réus. O acusado Diego Fernando não tinha dinheiro e não se recorda se o outro corréu tinha dinheiro.

A testemunha Willian dos Santos Oliveira, policial militar, apresentou relato semelhante ao de seu colega Jonatas. Disse também que abordou um dos indivíduos que estava com uma sacola nas mãos, detendo-o. Esse indivíduo estava traficando quando outro policial o abordou. Os dois acusados chamam Diego e não sabe apontar qual estava com a sacola. O local dos fatos tem prisão por tráfico de drogas toda semana. Disse que um dos acusados trazia a sacola e as porções estavam prontas para venda. Havia mais de cem porções. Narrou que um segurava a sacola e o outro foi detido por seu parceiro. Salvo engano, não tinha entorpecentes com o outro corréu detido por seu parceiro, mas ele avisou o réu que trazia a droga, sobre a chegada da polícia. O corréu abordado por seu parceiro disse que a função dele era avisar a chegada da polícia. Narrou que seu companheiro que avistou o cenário no começo da viela e seu companheiro narrou que um dos acusados gritou "corre, corre". Disse que somente vendo os autos sabe relatar qual o nome do acusado que atuava como "olheiro" e qual foi o que abordou. Declarou que o rapaz que seu companheiro abordou não tinha aspecto de morador de rua e ele disse que estava ali por causa de drogas. Não se recorda se com os acusados havia dinheiro.

O réu Diego Fernando dos Santos Dobkowski declarou em interrogatório judicial que tem 24 anos, é eletricitista e ganhava em torno de um salário mínimo e meio mensalmente. Estudou até o ensino médio completo. É solteiro e não tem filhos. Já foi processado antes por roubo e foi condenado. Disse que os fatos são verdadeiros. Veio para Arujá por causa de um emprego e não se adaptou à empresa. É usuário de crack e teve recaída. Disse que para poder usar drogas, aceitou realizar o tráfico. Narrou que era "olheiro" e ia ficar vendo se se aproximava alguém, mas não tinha drogas consigo. Não conhece o corréu Diego e não conhecia ninguém. Quando foi abordado pelos policiais estava só e não sabe se o réu tinha drogas. Foi abordado num local e o corréu em outro. Não quer responder se Diego Cardoso estava traficando. Afirmou que o dia do flagrante era seu primeiro dia como olheiro e iria receber pagamento em crack. Estava morando na rua quando foi preso.

O réu Diego Cardoso dos Santos declarou em interrogatório judicial que tem 30 anos, é polidor de carros e ganha um salário por mês, mais comissão e cesta básica. Estudou até o primeiro grau completo. É separado e tem um filho de oito anos, que mora com a mãe. Disse que foi processado em 2011 por ser usuário de drogas, não foi condenado. Disse que não são verdadeiros os fatos. Na data dos fatos foi procurar maconha e um rapaz que vendia. Deu o dinheiro para ele e ele foi para o mato. Depois o rapaz saiu correndo e a polícia chegou e o abordou. Narrou que na viela havia mais pessoas, só que a polícia liberou todos e ficou só ele e o corréu, por terem o mesmo nome. Afirmou que ainda não tinha recebido a droga do rapaz que traficava, mas chegou a dar o dinheiro para ele. Narrou que não viu a sacola com

drogas que os policiais acharam.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O acusado Diego Fernando em interrogatório judicial confessou que estava no local e data dos fatos, atuando como "olheiro" para o tráfico de drogas. Afirmou que faz uso de entorpecente e que iria receber como pagamento drogas, sendo aquele o primeiro dia que realizava a função. Declarou o acusado que não conhecia Diego Cardoso e, posteriormente, afirmou que não queria responder se o corréu Diego Cardoso estaria traficando. O acusado Diego Cardoso, em interrogatório judicial, negou que realizava tráfico de drogas, afirmando que somente teria ido ao local para adquirir maconha, tendo o rapaz que vendia a droga pegado seu dinheiro e corrido ao ver a polícia, que acabou lhe abordando, assim como o corréu.

Em sede policial o acusado Diego Cardoso apresentou versão diversa dos fatos (fls. 19), alegando que na data dos fatos os policiais o abordaram e olharam uma fotografia, falando "é ele mesmo", sendo preso em seguida. Afirmou em delegacia que na data dos fatos estava indo para a casa de sua mãe para procurar trabalho.

O acusado Diego Fernando, por seu turno, em delegacia apresentou a mesma versão dos fatos, confirmando que era "olheiro" do tráfico de drogas (fl. 28).

Os policiais ouvidos em juízo informaram como se deu a prisão dos réus e o encontro das drogas. Ambos os policiais confirmaram que um dos acusados tinha em sua posse uma sacola com drogas e o outro era pessoa que gritou avisando a chegada da polícia na viela. Pelos depoimentos dos policiais, resta claro que as porções de drogas estavam numa sacola que era trazida por Diego Cardoso. Em delegacia, os policiais deram a mesma versão dos fatos (fls. 02/04).

O exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 113/115).

Quanto aos depoimentos trazidos nos autos, tem-se que, embora não se possa utilizar elementos do inquérito policial como prova, no caso em questão, é a própria versão dos acusados em juízo que, contraposta aos relatos dos policiais e às demais provas colhidas, termina por conduzir à certeza de culpabilidade.

Este juízo vem sempre consignando que não seria demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a juntada de outras provas que não se limitem às declarações dos policiais que foram responsáveis pela prisão do agente, e que hoje já existem outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, como gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações.

Não obstante, as circunstâncias específicas do caso, mormente em relação às divergências nas versões apresentadas por Diego Cardoso, aliadas ao fato de os acusados estarem na mesma viela - na qual o acusado Diego Fernando admitiu atuar como "olheiro do tráfico" - revelam uma versão defensiva do corréu Diego Cardoso muito frágil e pouquíssimo convincente, a qual, por sua vez, acaba oferecendo elementos sobre a abordagem que se coadunam com a dinâmica relatada de forma uníssona pelos policiais, terminando por constituir um conjunto probatório suficiente à prolação de um decreto condenatório em desfavor dos réus.

Recorda-se que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO

FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDOTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consoma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Nota-se que a prova existente nos autos é suficiente para a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas.

Deveras, o réu Diego Fernando confessou que atuava como "olheiro do tráfico", conduta que se subsume ao delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas. Já em relação ao corréu Diego Cardoso, sua versão não se mostra crível, havendo divergências em seus depoimentos prestados, e os testemunhos policiais foram detalhados acerca de sua conduta e de que ele era quem portava a droga que estava sendo comercializada.

Outrossim, não há que se falar em atipicidade de conduta de "olheiro" ou emendatio libelli para o delito do art. 37, da lei de Drogas, uma vez que, como dito, a conduta praticada por Diego Fernando se subsume ao art. 33, tratando-se de tráfico de drogas.

Isso porque a conduta descrita pelo tipo do art. 37, da Lei 11.343/06 se refere a quem atua como informante de grupo, organização ou associação que realiza tráfico de drogas, o que é diverso da função de "olheiro" desempenhada pelo réu Diego Fernando.

Dispõe referido art. 37, da Lei de Drogas:

"Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei"

Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. Ré revel. 2. Tese desclassificatória para o delito tipificado pelo art. 37 da Lei Antidrogas. Acusada que atuava como "olheira". O referido tipo penal tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo, associação ou organização criminosa, desde que não tenha envolvimento ou relação com as atividades desempenhadas pelos integrantes daquele grupo, associação ou organização para os quais atua na condição de informante. Caso comprovado que o envolvimento do agente não se limita à mera colaboração como informante, mas que mantenha vínculos mais intensos, colaborando com as práticas delitivas, não será qualificado como mero "informante colaborador", subsumível ao art. 37 da Lei de Drogas. 3. Hipótese fática em que a acusada atuava como olheira do tráfico situando-se em local estratégico próximo à viela em que os entorpecentes eram comercializados pelo corréu. Impossibilidade de acolhimento da tese desclassificatória. Exercício do tráfico em coautoria. 4. Dosimetria. Pena-base fixada no limite mínimo. Tráfico privilegiado caracterizado. Acusada primária sem antecedentes criminais. Inexistência de elementos que afirmem a sua dedicação à prática de atividades criminosas ou o envolvimento com organização criminosa. Quantidade não expressiva de drogas. Modulação da causa de diminuição com redução da reprimenda em metade. 5. Modificação do regime prisional para o aberto.

Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 6. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1503708-18.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Conclui-se, deste modo, que Diego Fernando atuou como coautor do delito de tráfico de drogas, na forma descrita na denúncia.

Ainda, alegou a defesa de Diego Fernando a inexigibilidade de conduta diversa, por ser estar o réu em situação de rua quando do flagrante e por ser usuário de drogas.

Anoto, por oportuno, que a defesa não requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica.

Também, o mero fato de ser usuário de drogas não acarreta a excludente de culpabilidade, não havendo nos autos provas de que o acusado não seria capaz de entender o caráter ilícito do fato.

Neste sentido:

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Réu detido em flagrante na posse de 44,60g de crack. Recurso defensivo, alegando, preliminarmente, a configuração de nulidade processual por indeferimento do exame toxicológico. Nulidade não configurada. Inexistem nos autos elementos a justificar a necessidade de realização do exame. Insurgência revestida na intenção de obter declaração de imputabilidade. Réu não se mostrou incapaz, parcial ou totalmente, de entender o caráter ilícito da conduta. No mérito, argui a tese de inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade. No máximo, o presente caso retrata a situação de traficante usuário, sendo o porte de droga para consumo próprio absorvido pelo delito de tráfico. Condenação. Penas dosadas nos patamares mínimos. Causa de diminuição aplicada no máximo. Contudo, a substituição, apesar de possível, não é indicada. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0004285-62.2011.8.26.0483; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/08/2012; Data de Registro: 24/08/2012)

O acusado Diego Fernando é reincidente, pois tem condenação anterior por delito de roubo (fls. 52/53). O acusado Diego Cardoso é primário (fls. 50/51) e deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu ostenta bons antecedentes e inexistem nos autos comprovação suficiente de que se dedique a atividade criminosa. Demais disso, a diversidade de drogas não obsta o reconhecimento da minorante.

Nesse sentido, o aresto abaixo colacionado.

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico de drogas. Recurso ministerial. Pleito de condenação dos apelados como incursos no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Provas suficientes de autoria e materialidade apenas em relação ao tráfico. Mantida a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, ante a ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência do suposto grupo criminoso. Dosimetria das penas. Confirmado o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no grau máximo. Primariedade, quantidade de droga que não se mostra excessiva e inexistência de elementos que indiquem a dedicação à atividade criminosa ou integração a organização voltada à prática de delitos. Regime inicial aberto e substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos mantidos nos termos da r. sentença. Evidente erro material na r. sentença

em relação às penas de multa. Viável a sua correção. Negado provimento ao recurso, com correção, de ofício, do erro material constante do dispositivo da r. sentença. (TJSP; Apelação 0046355-59.2016.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017) (grifos nossos)

Ainda, inexistiu qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente os réus de pena em relação ao delito de tráfico.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois os réus eram (e ainda são) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR DIEGO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado no autos, como incurso nas penas do art. 33, §4º, c.c. da Lei 11.343/06 e DIEGO FERNANDO DOS SANTOS DOBKOWSKI, qualificado no autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06..

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena.

1) Em relação ao acusado DIEGO CARDOSO DOS SANTOS:

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes (fls. 50/51). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias também não se revelam desfavoráveis ao acusado, lembrando que a quantidade e natureza da droga não apresentam expressão ou magnitude aptas a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso, imponho ao réu a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Na segunda fase, observo estarem ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.

Presente, todavia, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação prova bastante de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão "as penas poderão ser reduzidas", não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao

Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

"A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena" (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Ainda, é preciso salientar que com o acusado não foi encontrado qualquer tipo de armamento, ou quantia mais expressiva em dinheiro e o crime, ao que consta, não envolveu qualquer tipo de ameaça, violência ou intimidação.

Outrossim, a diversidade de natureza de drogas, a par de não ser elemento suficiente a afastar a minorante, também não o é para modular a fração do benefício.

Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 - SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Diante disto, cabível a redução à razão de 2/3.

Nesse contexto, à míngua de outras causas modificadoras, fica o réu DIEGO CARDOSO DOS SANTOS, definitivamente condenada por tráfico de drogas privilegiado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, cumulada com 166 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais:

O parágrafo 4^a do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de

drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos gravosos. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena aplicada ao réu, mas também se funda na determinação de sua qualidade ou natureza. Se a culpabilidade do réu é de menor grau, sustentando a lei uma diminuição da pena imposta, não subsiste razão jurídica para obstar ao réu a concessão de benefícios penais condizentes com a sua menor culpabilidade.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é mecanismo salutar e consentâneo com os primados do Estado Democrático de Direito em que vivemos, sendo, em caso como ora apresentado, bastante a demonstrar a reprovação do Estado com relação à conduta perpetrada pela agente, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, mormente no tocante a presos que cometeram pequenos delitos, como o ora acusado.

A vedação outrora inserta no art. 33, §4º da lei 11.343/06 que impedia a substituição da pena privativa imposta revelava-se incoerente e arbitrária, destoando dos preceitos constitucionais aos quais deve estar atrelada, motivo pelo qual deveria ter sua aplicação afastada. Aliás, tal providência é hoje desnecessária, uma vez que o Senado Federal, desde 16.02.2012, seguindo a linha da jurisprudência dos tribunais, resolveu por bem baixar a resolução nº 05/2012, suspendendo a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, de modo que desde tal data, não subsiste mais qualquer empecilho legal à substituição da pena nos casos de tráfico privilegiado.

Também afastada deve ser a regra inserta no art. art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pelas mesmas razões declinadas relativas ao dispositivo que vedava a substituição da pena.

Aliás, o próprio STF, já vem entendendo - além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não

reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016)

PENA - REGIME FECHADO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de 2 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC 129714, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2017 PUBLIC 26-04-2017) (grifos nossos)

Esse mesmo entendimento vem sendo seguido pelo STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO MÁXIMA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE PRIMÁRIA, CONDENADA À PENA QUE NÃO EXCEDE 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência (HC n.126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016). 3. No caso, a jurisdição das instâncias ordinárias encontra-se encerrada, porquanto na fase de admissibilidade do recurso especial interposto pelo paciente, sendo possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No caso, verifico que a quantidade de entorpecentes não é expressiva para aplicar a fração em patamar diverso do máximo, com relevo para o fato de que a paciente era menor de 21 anos na data do fato, é primária, está grávida e já está inserida no mercado de

trabalho. Assim, o redutor comporta aplicação em seu patamar máximo.6. Em relação ao regime, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal.7. No caso, o regime fechado, mais severo do que a pena comporta, foi fixado com base na hediondez do delito e na gravidade abstrata da conduta, fundamentos que não são considerados idôneos para fixar o regime mais gravoso. 8. Dessa forma, tratando-se de ré primária, condenada à pena privativa de liberdade não superior a 4 anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, a paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença.(HC 391.679/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

Com efeito, seguindo a linha do que vem sendo sustentado pelos tribunais superiores, é, de fato, inevitável o reconhecimento da invalidade da norma proibitiva do início de cumprimento da pena em regime diverso do fechado pela violação ao devido processo legislativo, por não observar os comandos constitucionais de individualização da pena, porque, embora tenha cominado para o mesmo crime penas diversas em razão das condições pessoais dos acusados, com reconhecimento do excesso de penas ao primário, exige-lhe igual recolhimento ao cárcere, em regime fechado, a afrontar também o princípio da proporcionalidade.

Não se pretende assumir poderes legislativos, mas a aproximação do Direito Penal ao Direito Constitucional implica interpretar as normas penais ao influxo da Constituição da República para verificação da validade daquelas normas que, inevitavelmente, devem conter os direitos fundamentais, além de serem proporcionais e razoáveis às relações humanas, princípios impeditivos de excessos, da pena desnecessária.

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial será o ABERTO, que deve ser estabelecido com observância às circunstâncias judiciais, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal. Fixada a pena-base no mínimo legal, o regime inicial deve ser adequado à quantidade da pena, que no presente caso permite o estabelecimento do regime aberto, porque o acusado não é delinquente contumaz, como pode ser inferido das provas acostadas e folha de antecedentes.

Atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal. Sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, aplico também a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidades públicas ou privadas, a ser especificada pelo juízo de Execução, sem prejuízo do pagamento dos 166 dias-multa já fixados.

Assim, fica o réu DIEGO CARDOSO DOS SANTOS definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, para início no REGIME ABERTO, que SUBSTITUO por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 01 (um) salário mínimo como prestação pecuniária, além de 166 dias-

multa cominada no tipo penal, no valor mínimo legal.

O réu está preso desde 22/01/2021. Deixo de aplicar o disposto no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo em que o réu esteve preso provisoriamente, não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Do direito do réu apelar em liberdade:

O réu respondeu preso ao processo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a pena aplicada, a sua substituição e o regime fixado, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu Diego Cardoso dos Santos com urgência.

2)Em relação ao réu DIEGO FERNANDO DOS SANTOS DOBKOWSKI:

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que a ré agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes, servindo a condenação anterior como reincidência (fls. 52/53). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias também não se revelam desfavoráveis ao acusado, lembrando que a quantidade e natureza da droga não apresentam expressão ou magnitude aptas a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso, imponho ao réu a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Incide a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Portanto, tenho por bem em compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em circunstância preponderante.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da

reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 11/4/2005). III - Na espécie, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. Incidência da Súmula n. 545/STJ. IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema. VI - A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi fixada em 1/5 (um quinto) com base em elementos concretos e de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração da reprimenda. VII - Ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal, sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. VIII - A eventual possibilidade de aplicação do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua análise neste Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do paciente para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (HC 365.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 23/11/2017)

Portanto, mantenho a pena no patamar outrora fixado.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fica o réu DIEGO FERNANDO DOS SANTOS DOBKOWSKI definitivamente condenado pelo delito de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão cumulada com 500 dias-multa, no mínimo legal.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais:

Conforme estabelece o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Sobre a detração a que se refere o dispositivo em questão, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UM DOS RÉUS PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO CORRETAMENTE APLICADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PENA RESTANTE INFERIOR A 4 ANOS. REGIMES ALTERADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios

empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Malgrado a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade do réu não conduzam, necessariamente, à fixação do regime prisional menos severo, os fundamentos genéricos utilizados pelas instâncias ordinárias não constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso a Gilberto que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). 4. Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudesimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda imposta a Gilberto ser cumprida, desde logo, em regime semiaberto. 5. Quanto a Rodrigo, em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP. 6. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Precedentes. 7. Considerando que os pacientes permaneceram presos provisoriamente por mais de 1 ano e 4 meses, a Gilberto deve ser estabelecido o regime aberto, eis que aplicada a detração, a pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o que permite a fixação do regime prisional menos gravoso, considerando que lhe foram favoravelmente sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Quanto a Rodrigo, deve ser estabelecido o regime semiaberto, pois, mesmo que aplicada pena inferior a 4 anos, a condição de reincidente impede que lhe seja permitido o desconto da reprimenda no regime prisional menos gravoso. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para estabelecer os regimes prisionais aberto a Gilberto e semiaberto a Rodrigo para o início do desconto da pena a eles imposta. (HC 424.984/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifos nossos)

Assim, mesmo sendo o réu reincidente, considerando o art. 387, §º, do Código de Processo Penal e o fato de que o acusado encontrar-se cumprindo prisão provisória desde 22/01/2021, ou seja, há mais de (01) um ano e (02) dois meses, inexistindo ademais circunstâncias judiciais negativas, deverá o réu